

1500226-21.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... CORPUS - Penal e Processual Penal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Causa de diminuição da pena - Artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06 - Não-preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício - Ordem denegada.

1. Segundo o parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06, nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500226-21.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500226-21.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA, em hora e local descritos na inicial acusatória, transportava, para consumo de terceiros, a substância entorpecente mencionada na peça inaugural.

Em razão dos fatos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Denúncia recebida à fl. 86. Audiência de instrução realizada por meio audiovisual. No curso da audiência houve aditamento oral à acusação, com a inclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, já que o requerido reconheceu que realizava o transporte interestadual das drogas. As partes dispensaram novo interrogatório.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 115/117, bem como toda a

prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, também é certa.

Em juízo, o policial rodoviário federal inquirido confirmou o depoimento administrativo de fl. 04, sem inovação substancial. Acrescentou que os entorpecentes não estavam escondidos, encontrando-se em cima dos bancos e dentro do porta-malas.

Inquirido em juízo, o réu disse que fora contratado por uma pessoa cujo nome não indicou, com a incumbência de levar o carregamento do Estado do Paraná até uma cidade em São Paulo. Que iria receber 20 mil reais pelo transporte. Que o seu contratante disse se tratar de transporte "arriscado". Que não sabia que se cuidava de entorpecentes.

A tese do réu quanto ao desconhecimento do conteúdo dos embrulhos não merece guarida, por óbvio, já que o próprio contratante disse que seria um transporte "arriscado". Ademais, o PRF ouvido em audiência relatou que as drogas sequer estavam escondidas, antes se encontravam à vista de qualquer pessoa. Por fim, parece bastante improvável que alguém aceitasse fazer uma viagem interestadual, com uma "bagagem" de mais de 300 quilos, recebendo significativo montante (20 mil reais), sem saber o que levava ao destino...

A condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

2. Na primeira fase, existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base.

O crime envolveu enorme quantidade de tóxicos, 365 quilos de maconha.

A jurisprudência do STF já se solidificou no sentido de a quantidade de entorpecente servir, dependendo do caso concreto, como fundamento ao aumento da pena-base, quando da aferição das circunstâncias do crime. Nesse sentido: HC 78.383-5; DJ 21/05/1999.

Na mesma linha de raciocínio, decisório do Superior Tribunal de Justiça (grifos meus):

"CRIMINAL - HC - Tráfico de entorpecentes - Dosimetria - Pena-base - Circunstâncias judiciais devidamente analisadas - Consideração de peculiaridades concretas do delito - Quantidade da droga apreendida - Objetivo de lucro fácil - Prejuízo à saúde pública - Exasperação fundamentadamente procedida - Observância do método trifásico - Inexistência de constrangimento ilegal - Confissão espontânea - Não-ocorrência - Condenação com base nas demais provas dos autos - Associação eventual para o tráfico - Majoração acima do mínimo legal com fundamento na quantidade da droga apreendida - Bis in idem - Constrangimento ilegal evidenciado - Progressão de regime - Delito hediondo - Impossibilidade - Lei nº 8.072/90 - Constitucionalidade - Inexistência de ofensa ao princípio da individualização da pena - Ordem parcialmente concedida.

...

II. O magistrado singular, para a aplicação da pena-base, procedeu ao correto exame das circunstâncias judiciais, considerando as peculiaridades concretas do delito de tráfico de drogas em questão, tais como a quantidade da droga apreendida, o objetivo de lucro fácil e as graves consequências à saúde pública, aspectos caracterizadores da referida prática criminosa que não são inerentes ao tipo penal, ao contrário do que sustenta a impetração.

..."

(STJ - HC nº 46.791/SC - 5ª T. - Rel. Ministro Gilson Dipp - J. 03.11.2005 - DJ 21.11.2005).

Contudo reconheço que o STF pacificou o entendimento no sentido da impossibilidade de valoração negativa da mesma circunstância (quantidade ou qualidade do entorpecente) em mais de uma fase do critério trifásico, sob pena de bis in idem em desfavor do condenado (ARE 666.334/AM), posicionamento que também passou a ser adotado pelo STJ (HC 283.063/PI).

Assim, como doravante negarei a minorante do art. 33, par. 4º, com fulcro exatamente na quantidade, deixo de valorar tal circunstância, rendendo-me à orientação dos Tribunais Superiores.

Na segunda fase, nada a computar.

Na terceira etapa, encontra-se presente a majorante do inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06, vez que o caráter interestadual do transporte dos entorpecentes é incontroverso, já que o próprio inculpado afirma que saiu do Paraná com destino a São Paulo.

Quanto à calibragem do aumento, de modo a, novamente, evitar bis in idem, majoro a exprobração no patamar mínimo de 1/6, estipulando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Em desfecho, o réu não faz jus à minorante do art. 33, par. 4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, malgrado se trate de não reincidente, a estrondosa quantidade de droga apreendida, aliada ao eloquente numerário que o réu iria receber por sua participação no delito, fazem presumir se cuidar de indivíduo dedicado a atividades criminosas habituais, em franca oposição ao "espírito" do redutor em comento, o qual veio a lume com o objetivo de estreimar o pequeno traficante dos grandes barões da traficância. Em caso similar ao presente, o STJ assim se posicionou (grifei):

"HABEAS CORPUS - Penal e Processual Penal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Causa de diminuição da pena - Artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06 - Não-preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício - Ordem denegada.

1. Segundo o parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06, nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. É inaplicável a minorante legal ao caso, uma vez que, embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, ele não atende ao requisito previsto no mencionado dispositivo atinente à vedação de se dedicar a atividade criminosa, pois restou evidenciada nos autos a prática do tráfico, em razão da grande quantidade da substância entorpecente apreendida. Precedentes do STJ.

3. Ordem denegada".

(STJ - HC nº 111.891 - GO - 5ª T. - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - J. 06.11.2008 - DJe 24.11.2008).

Na mesma toada, decisórios do Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei):

"PENA - Fixação - Tóxicos - Causa de diminuição da reprimenda prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Grande quantidade de droga e demais circunstâncias do crime - Incidência - O mencionado parágrafo não pode ser sopesado isoladamente, sob pena de extrair do magistrado a tarefa jurisdicional de individualização da sanção penal - Causa de diminuição que deve ser analisada em consonância com os artigos 42 do mesmo diploma e 59 do Código Penal, sem o que não haverá critérios norteadores a fim de se estabelecer o "quantum" da redução - Além

do mais, o transporte de mais de noventa e dois quilos de drogas é um forte indicativo de que o réu pertence à organização criminosa, pois não é crível que quantidade acentuada seja disponibilizada à terceira pessoa sem vínculos com o grupo criminoso - Inexistência de "bis in idem" - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Ap. nº 990.09.235.136-2 - Presidente Epitácio - 10ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida - J. 29.07.2010 - v.u).

"PENA - Fixação - Tráfico de entorpecentes - Incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 11.343/06 - Descabimento, por não se tratar de pequena e eventual traficante - Ré condenada por guardar grande quantidade de porções individualizadas da droga, o que permitiria ampla difusão, atingindo número considerável de pessoas - Apreensão, ainda, de balança de precisão e sacola contendo frascos vazios - Circunstâncias indicativas de que a agente se dedicava à atividade organizada do tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público provido para afastar a referida causa de diminuição de pena". (TJSP - Ap. nº 990.10.093.274-8 - São Paulo - 15ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Amado de Faria Souza - J. 15.07.2010 - v.u).

É evidente que a quantidade de entorpecentes pode ser sopesada como elemento indiciário, a sinalizar envolvimento aprofundado na criminalidade, até porque seria absolutamente inusitado que um traficante de "primeira viagem" fizesse o transporte de tal montante de drogas.

Como pontificou o TJSP na apelação criminal nº 1500859-03.2020.8.26.0628, oriunda desta Comarca:

"Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux)".

Mesmo porque, como muito bem pontuou o Ministro Luiz Fux no julgado acima mencionado: "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'".

Pena fixada definitivamente em 5 anos e 10 meses de reclusão.

2.1. Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da nova Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 583. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo o dia-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

2.2. Passo a deliberar sobre o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

Mudando o meu posicionamento, passei a entender viável a imposição legal de início de cumprimento de pena em regime inicial fechado, independentemente de singularidades do caso concreto. Explico.

É verdade que o STF já considerou inconstitucional a determinação de regime inicial obrigatoriamente fechado (art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos), cabendo ao juiz do caso o estabelecimento do regime a partir da aferição dos elementos

concretos do processo (HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012).

Todavia, não há decisão em tal sentido prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade; logo, inexistente efeito vinculante a manietar os demais órgãos judiciários.

Ademais, o próprio STF, ao que parece, vem vacilando sobre o tema.

É que, recentemente, a 1ª Turma daquela Corte Constitucional reputou constitucional o art. 1º, par. 7º, da Lei n. 9455/97, que estabelece, como regra, cumprimento de pena em regime inicial fechado para os condenados pelo crime de tortura (HC 123316/SE, rel. Min. Marco Aurélio, 9.6.2015).

Vale ressaltar que a tortura e o tráfico de entorpecentes receberam o mesmo tratamento pelo constituinte originário (art. 5º, XLIII, CF/88).

Não há qualquer razão, portanto, para conferir ao condenado por tráfico tratamento mais benevolente do que o concedido ao apenado pelo delito de tortura -- sendo conveniente lembrar, aliás, que o crime de tortura, salvo quando resulte em morte da vítima, possui pena-base inferior ao de tráfico.

Enfim, deve ser homenageado o art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

De qualquer forma, ainda que fosse deixado de lado o dispositivo supra, é fato que qualquer outro regime não fará frente aos objetivos da prevenção e reprovação do crime (art. 59, caput, parte final, CP), em vista da gravidade em concreto do delito praticado, o que autorizou, destarte, a majoração da objurgação e a negativa de diminuição na última etapa do trajeto censório.

Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz, é claro, do quantum censurador.

3. Ante o exposto, declaro o réu ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA, incurso no artigo 33, caput, c/c artigo, 40, V, ambos da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa cada, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

4. O réu, que respondeu ao feito preso, assim deve permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que o exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial diverso do aberto pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorável. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

"O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade"
(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

5. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

6. Custas na forma da legislação estadual.

7. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

8. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP. Especificamente quanto ao veículo apreendido, expeça-se o necessário para sua devolução à proprietária (apenso próprio).

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA